

1501008-03.2021.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... encontradas no imóvel usado ponto de tráfico de drogas, portanto, suas versões são fantasiosas e desconexas com o conjunto probatório coligido aos autos.

Os demais elementos de prova dos autos demonstram a ocorrência do delito de tráfico de drogas diante da conduta do réu, não só pela apreensão das drogas nos dias dos fatos, mas pela ocorrência dos fatos como informado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501008-03.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501008-03.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO SERGIO COSTA SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra PAULO SERGIO COSTA SOUZA, vulgo "Pitbull", qualificado às fls. 06/07, imputando-lhe a prática do crime descrito nos artigos 33, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de novembro de 2021, por volta de 15h32min, na Rua José Carlos Pimenta, próximo ao numeral 150, Jardim Marisa, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente/SP, PAULO SERGIO COSTA SOUZA, vulgo "Pitbull", qualificado às fls. 06/07, mantinha em depósito 106,11 (cento e seis gramas e onze decigramas) de maconha, armazenados em duas porções, com o fim de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização ou

em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 27/28, fotografia de fl. 29, auto de constatação preliminar de fl. 30 e laudo pericial definitivo a ser oportunamente juntado. Segundo apurado, o denunciado adquiriu a substância entorpecente acima mencionada de pessoa desconhecida e a manteve em sua residência para posterior revenda a dependentes químicos. Contudo, no dia dos fatos, em cumprimento de diligência visando averiguar outra ocorrência, versando sobre furto e ulterior receptação da res furtiva pelo denunciado, policiais militares se dirigiram a residência de PAULO SERGIO. No local, localizaram duas porções grandes da droga e material para preparo do entorpecente. Ainda, na residência do denunciado foi encontrada parte dos bens subtraídos, tudo a indicar que foram permutados por entorpecentes. O denunciado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. Requisitou-se exame pericial definitivo da droga apreendida. As circunstâncias em que se deram os fatos, somadas à quantidade de droga apreendida, a forma como a porção estava dividida e armazenada, afigura-se quadro seguro a apontar que seria destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes.”. Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial. Após regular citação apresentado defesa preliminar (fls. 96/97), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 101/102), o despacho de fls. 103/107, de 14 de janeiro de 2022, recebeu a denúncia e determinou a produção de provas. Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 131/132), pediu a parcial procedência da ação penal, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, o ilustre Dr. Defensor Público (fls. 131/132), arguiu preliminarmente, a ilicitude da prova angariada aos autos, vez que o ingresso de policiais militares no interior do imóvel residencial dos autuados, sem o correspondente mandado de busca e apreensão e autorização de morador, já que deveria ter sido toda a ação gravada por sistema audiovisual, portanto, toda a prova torna-se ilícita e corrompe toda a sua derivação, devendo ser absolvido nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. No mérito, requer a absolvição do réu, por insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de drogas, por não se vislumbra qualquer prova que a droga se destinava a fornecimento de terceiros, e por outro lado a única testemunha não foi ouvida em Juízo para confirmar sua versão inicial, bem como o rolo de papel alumínio, causa estranheza a apreensão deste objeto, já que o Policial disse que apreendeu a parte do rolo que ainda não tenha sido utilizada, e que o pedaço que foi submetido a perícia, não foi o mesmo apreendido na casa do acusado, uma vez que não foi observado as regras do artigo 158, do Código de Processo Penal, pois não houve o acondicionamento e lacração do objeto onde ele fora encontrado, pelo contrário, os policiais recolheram os objetos e levaram a delegacia que somente lá houve a lacração, portanto, devendo o réu ser absolvido nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Requer também, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no artigo 28, da Lei nº 11343/06, pois o réu alega em Juízo ser usuário de drogas. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, que seja aplicada a pena no mínimo legal, em regime aberto, e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, reconhecendo a figura do tráfico privilegiado, devendo ser reconhecida, até porque os objetos apreendidos não são compatíveis de que havia habitualidade na prática delitiva.

É o relatório.

DECIDO.

Primeiramente, quanto à alegação de nulidade, decorrente de violação ao domicílio, entendo que não há como ser acolhida, visto que se tratando de flagrante delito, não se mostra possível alegar a referida garantia constitucional.

No caso dos autos, tais circunstâncias mostram-se suficientes para o afastamento de qualquer alegação de nulidade da prova.

Até porque havia fundadas e sérias razões para ingressar na residência onde o réu estava, tanto, que ao os Policiais Militares, ao chegarem na residência, se depararam com a namorada do réu que autorizou a entrada da equipe policial, diante das informações que possuíam acerca de objetos produtos de furto no local, e por fim, encontram uma grande quantidade de drogas com o réu, que da forma em que foram localizadas, evidenciam sobremaneira a traficância no local, além do cometimento de

outros crimes, que possivelmente estão sendo apurados em outro procedimento.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. RECORRENTE ABORDADA EM VIA PÚBLICA, OCASIÃO EM QUE FOI ENCONTRA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS, ANTES DA ENTRADA DOS AGENTES EM DOMICÍLIO ALHEIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - No que tange ao pedido de reconhecimento de nulidade, pela ausência de mandado de busca e apreensão, insta consignar que tanto a jurisprudência desta Corte, como a do eg. Supremo Tribunal Federal, firmaram o entendimento no sentido de que, tratando-se de crime permanente, como é o delito de tráfico de entorpecentes mostra-se prescindível o mandado judicial, em caso de flagrante, como na hipótese. III - No caso, sub examine, no qual se alega a ocorrência de irregularidade face a ausência de mandado judicial, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a atuação dos agentes policiais no sentido de ingressar em domicílio alheio teve como elementos precursor e a abordagem realizada em via pública, "[...]momento que encontraram pequena porção de substâncias entorpecentes", bem como informação acerca da existência de mais droga no local em que ela reside, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada.

Ademais, a ocorrência do crime permanente foi confirmada no momento da atuação policial, mediante a apreensão da droga, não havendo que se falar em ausência de situação de flagrante. IV - A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. V - In casu, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade da ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a contumácia delitiva da ora Agravante, porquanto, consoante se deduz dos autos, a conduta, em exame, não é fato isolado na sua vida, tendo o magistrado primevo ressaltado na decisão objurgada que ela "já responde a outra ação penal também pelo crime de tráfico de drogas (0007559-75.2018.805.0191), onde foi concedida liberdade cumulada com medidas cautelares diversas da prisão", circunstância que indica a periculosidade concreta da agente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. VI - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC140.998/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Segundo o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgrR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgrR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em

fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1281760 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020).

É que quando se trata de crime permanente, como o porte de arma e de munição, não há a invasão preconizada, pois a flagrância protraí-se no tempo, podendo, a qualquer momento, o policial prender o réu. Existe, ainda, exceção à necessidade de mandado de busca e apreensão. Não existe, pois, violação de preceito constitucional, art. 5º, XI, da Carta Magna, ou legal (art. 303 do Código de Processo Penal).

A prisão foi feita em conformidade com os ditames legais. O direito em análise não é absoluto, quando há flagrância, pode-se agir, caso contrário, outro tipo de violação poderia ocorrer, até mais grave. "Este Tribunal Superior prega que, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, a sua consumação se protraí no tempo, de sorte que a situação de flagrância configura-se enquanto o entorpecente estiver sob o poder do infrator, sendo possível, portanto, em tal hipótese, o ingresso na residência, ainda que não haja mandado de prisão ou de busca e apreensão, já que incide a excepcionalidade inscrita no art. 5º, inciso XI, da CF, a afastar a inviolabilidade do domicílio" (HC 208957/SP- 6ª T. do Superior Tribunal de Justiça - Relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS) - J. 6.12.2011 - DJe 19.12.2011). Cf., ainda, HC 101628/SP - 6ª T. do Superior Tribunal de Justiça - Relatora Ministra Jane Silva (Desembargadora convocado do TJ/MG) - J. 21.10.2008 - DJe 10.11.2008; HC77489/AM- 6ª T. do Superior Tribunal de Justiça - Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura - J. 12.2.2008 - DJe 17.3.2008; HC 40056/SP - 6ª T. do Superior Tribunal de Justiça - Relator Ministro Hamilton Carvalhido - J. 30.6.2005 - DJ 05.09.2005, p. 493; HC 32934/GO- 5ª do Superior Tribunal de Justiça - Relator Ministro Gilson Dipp - J. 28.4.2004 - DJ 14.6.2004, p. 258 e RHC 14946/SP - 5ª T. do Superior Tribunal de Justiça - Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca - J. 1.4.2004 - DJ 03.05.2004, p. 184 e REVFOR vol. 375, p. 406).

O C. Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que: 'A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori' (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Tal matéria, todavia, foi suscitada novamente e em reexame do tema pelo Superior Tribunal de Justiça e no julgamento de Habeas Corpus nº 598.051 - SP (2020/0176244-9) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no dia 2/3/2021, decidiu:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. [...] 9. Na espécie, não havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificassem a invasão de domicílio do suspeito, porquanto a simples avaliação subjetiva dos policiais era insuficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência, visto que não foi encontrado nenhum entorpecente na busca pessoa realizada em via pública. 10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, conseqüentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. 11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova

derivada de conduta ilícita – no caso, a apreensão, após invasão desautorizada da residência do paciente, de 109 g de maconha –, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas. 12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e consequente absolvição do paciente [...] (HC 598.051/SP. MATÉRIA CRIMINAL. Relator Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 6ª Turma. JULGADO: 02/03/2021. Publ. 15/03/2021).

O Min. Relator Rogério Cruz justificou a decisão da turma em que, somente fundadas razões e desconfianças dos agentes do estado, não são suficientes para o ingresso sem mandado judicial na casa do suspeito, e além disso, “deve haver documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado, seja toda registrada em áudio e vídeo, de maneira a não deixar dúvidas quanto a legalidade da ação estatal e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado”. Entretanto, tal matéria foi objeto de análise em sede de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, e teve como Relator Min. Alexandre de Moraes, que decidiu de acordo com a repercussão geral daquela Corte quando descreve “o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Também ponderou que a TESE é de que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”.

Sem mais aprofundamento sobre a matéria e esgotada toda e qualquer discussão acerca do tema, merece então trazermos a parte final do julgamento que ocorreu no dia 02/12/2021, pelo Ministro Alexandre de Moraes, conforme segue:

“Diante de todo o exposto, em face do decidido no Tema 280 de Repercussão Geral, CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO E ANULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO tão somente na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação (itens 7,1, 7.2, 8, 12, e 13 da Ementa)[...].”

Portanto, os traficantes já estão cientes de que houve um julgamento sobre a possibilidade de ingresso na residência para prender traficantes, que a princípio, como podemos analisar, foi julgado ilegal qualquer ingresso sem autorização no domicílio para prender pessoa que porta drogas, devendo ainda a ação ser filmada por aparelho que capta audiovisual, conforme requer o Defensor Público, entretanto, todo operador do direito tem o dever de estar atualizado com as mais recentes decisões, como esta última do C. Supremo Tribunal Federal que anulou decisão do STJ, tão somente, no que diz respeito ao registro e documentação por aparelho audiovisual, e manteve a decisão de tornar legítimo o ingresso da Autoridade Policial no domicílio que estava ocorrendo qualquer tipo de crime, especialmente o crime de tráfico de drogas, que é permanente e tem seus efeitos até que seja cessada a atividade criminosa.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados ao réu, encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls. 27/28 e fotografia de fls. 29; pelo auto de constatação preliminar de fls. 30; pelo laudo químico toxicológico de fls. 92/94, atestando - Item Único (Acondicionado sob o lacre 0036121 ) Descrição: 2 (dois) invólucro(s) sendo um constituído de plástico(s) fechado(s) por nó e outro por papel alumínio retorcido encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos. Massa Bruta e/ou Quantidade: 110,34 grama(s) - cento e dez gramas e trinta e quatro centigramas. Massa Líquida: 103,03 grama(s) - cento e três gramas e três centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); Laudo pericial de objetos de fls. 89/91 que analisou - Item A (Acondicionado sob o lacre 018458 ) Descrição: 1 (uma) faca, sem marca aparente, constituída por uma lâmina metálica cortante presa a um cabo de plástico branco, apresentando resquícios/sujidades. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores, assim como foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020) e Item B (Acondicionado sob o lacre 018459 ) Descrição: 1 (um) rolo de papel alumínio, sem marca aparente, com folha de papel alumínio de 30 cm de largura, apresentando resquícios/sujidades. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); além da prova oral carreada para os autos.

Em Juízo, o PM Leandro Henrique Claudino Ignácio, sob o crivo do contraditório declarou que estavam em patrulhamento na noite em que houve um furto e tiveram conhecimento que os objetos estariam no endereço da casa do réu. Lá chegando sua namorada estava varrendo o lado de fora e autorizou a entrada da polícia, dizendo que nada de ilícito havia na casa e acabaram por surpreender o réu na posse de drogas e dos objetos furtados. Foi encaminhado a Delegacia para as providências cabíveis. No local encontrava-se outra pessoa que foram conduzidos todos para a Delegacia, sua namorada, uma terceira pessoa e o acusado. O local é conhecido por ser frequentado por usuários de drogas que lá compram e já usam no local, e Leonardo disse que comprou a droga de Ptibull e usou por lá mesmo. O acusado foi indagado sobre as drogas, disse que não sabia de onde vinha. Afirma que Leonardo estava no quintal da residência, não foi encontrada droga com ele, pois ele disse que já teria usado. O rolo de papel alumínio foi encontrado na casa do acusado, e já estava parcialmente usado, foi apreendida ainda no rolo e levado junto com a droga para ser apreendida.

O réu Paulo Sérgio Costa Souza, em seu interrogatório declarou que já foi preso e cumpriu pena somente por furto. Sobre os fatos disse que na verdade sobre os produtos roubados, e quando a polícia entrou estava dormindo e afirma que no local é frequentado por vários usuários de drogas, e que também é usuário de drogas. Quanto aos objetos não tem nada a ver com furto, estava dormindo, pois era 15:30 horas. Afirma que Leonardo não comprou nada consigo. Que a porção encontrada em sua residência já tinha usado uma parte, cortada uma parte para seu próprio uso. O papel alumínio é usado para forrar o fogão, não drogas, que toda residência tem papel alumínio. Que nenhuma droga foi encontrada embalada em papel alumínio, e que não mora sozinho naquela casa, tem outras pessoas que moravam lá também. Disse que fez tratamento no AME e ficou internado por causa de crack, cocaína e maconha, e não se lembra quando usou pela última vez. Ficou internado no AME por algum tempo, saiu, ficou um tempo de pé, mas depois voltou a usar.

A negativa do réu não pode ser acolhida, posto que além de não ser confirmada pela prova dos autos, está desmentida por ela, que demonstra de forma segura que os fatos se passaram como narrados na denúncia e a autoria deles pelo réu, além disso,

o réu apresentou justificativas, principalmente quanto aos objetos apreendidos dizendo que era o papel alumínio usado para forrar fogão e não para embalar drogas, todavia, caindo em total descrédito diante de tudo o que foi amealhado aos autos. Enquanto que Leonardo, que foi encontrado no quintal de sua residência, informou aos policiais militares que apenas usa o local para comprar drogas de Pitbull e que ele permite que se use drogas em sua própria residência, embora não tenha sido encontrado para confirmar sua versão, pois é comum que o usuário que compra drogas de traficante que é preso nesse momento, preferem se esquivar, possivelmente com medo de represálias, fato é que, a palavra dos policiais militares são de grande valor, e confirma essa versão da testemunha Leonardo, que compra drogas de Pitbull e usa no próprio local. Também se verificou e foi apreendido vários objetos produtos de furto, que comumente são usados para que os usuários subtraem e trocam por drogas.

Também não prospera a alegação de que a droga era para consumo próprio, já que também foi desmentida pela prova dos autos, vez que usuários relatam o tráfico de drogas no local, e é o que aconteceu nos autos, por denúncia de que objetos furtados estavam em poder do acusado, que segundo o Policial Militar Leandro, confirmou que compra drogas de Paulo Sérgio, vulgo Pitbull e ainda que ele permite que se use a droga adquirida em sua residência.

O depoimento dos policiais é suficiente para alicerçar a culpa do acusado, que deve provar sua inocência com os meios que obtiver.

Transcrevo decisões a respeito do crime ora tratado, relativamente à impossibilidade de desclassificação para uso de entorpecente, bem como sobre a credibilidade da palavra dos policiais envolvidos com a descoberta e detenção dos envolvidos:

"PROVA - Depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante - Declarações harmônicas e seguras - Suporte suficiente à condenação - Inteligência dos artigos 6º, III, e 202 do CPP. PROVA - Depoimento de policial - Credibilidade dos testemunhos em geral enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. ((RT 668/275 - TJSP - rel. Des. Jarbas Mazzoni))".

Nesse ponto, nunca é demais lembrar que "como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" - "Prova criminal - Testemunha - Hipótese de Tóxico. Depoimentos prestados por policiais. Validade. Presunção 'iuris tantum' de agirem escorreitamente no exercício da função. (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido: (RT 591/313 e 654/278).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. ((STF HC 74.608-0 de São Paulo rel. Min. Celso de Mello DJU 11.04.97, pág. 12.189))"

Observe-se que o depoimento dos policiais foi uníssono, seguindo no mesmo sentido e meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos, conforme pretende a defesa.

Aliás, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente a acusada, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia Militar.

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que "o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu

depoimento" (STF RHC Rel. Min. Moreira Alves JSTF-Lex 125/332).

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já decidiu o seguinte:

"Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivo expressos no CPP determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição" (TJSP AC Rel. Carlos Bueno RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

Demais disso, tem-se que "em sede de repressão aos tóxicos, contrapondo-se à palavra do agente à do policial-condutor, prevalece o depoimento do miliciano, salvo existência de prova diversa em contrário" (TACRIM-SP AC Rel. Lauro Malheiros JUTACRIM 30/328), valendo acrescentar que "pequenas divergências em depoimentos prestados pelas testemunhas, sem ofensa à essência do que contém, não são motivos para torná-los imprestáveis" (TJRJ EI Rel. Antônio Carlos Amorim RTJE 70/278).

Ademais, o desencontro da versão apresentada pelo réu, tanto em Juízo quanto em solo policial, acabam se confundindo com suas narrativas, justamente porque não encontram justificativas para a droga e os demais objetos usados para embalar drogas, inclusive uma faca com resquícios de droga encontradas no imóvel usado ponto de tráfico de drogas, portanto, suas versões são fantasiosas e desconexas com o conjunto probatório coligido aos autos.

Os demais elementos de prova dos autos demonstram a ocorrência do delito de tráfico de drogas diante da conduta do réu, não só pela apreensão das drogas nos dias dos fatos, mas pela ocorrência dos fatos como informado através da Polícia Militar; denotam o crime de tráfico.

Por tudo isso, demonstrada, á saciedade, a atividade espúria realizada pelo réu no imóvel onde reside e faz dele o seu ponto de comércio de drogas.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas contidos nos autos, anotando-se que a palavra da testemunha se reveste de coerência, robustez e segurança e não demonstra qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceita como elemento hábil à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-la, o que não fez.

Pelos detalhes acima extraídos da prova dos autos, não se pode acolher a negativa do réu e nem o pedido de desclassificação para o delito posse para consumo pessoal, já que é evidente a sua condição de traficante, em que pese tenham tentado justificar com a alegação de que ficou internado para tratamento do vício, e ainda que o fizesse para o sustento do seu próprio vício, não se deixaria de penalizar a conduta mais gravosa (tráfico de drogas), de forma que não há que se falar em desclassificação do crime denunciado para o previsto no artigo 28 da Lei especial, pois a mera alegação de ser usuário e de ter ficado internado para tratamento, não afasta, por si só, a condição de traficante.

Sobre o tema já decidiu esta C. Câmara:

"Além do mais, o fato de serem usuários de entorpecentes não exclui o de estarem também envolvidos com o tráfico, pois é comum usuários praticarem o comércio ilegal exatamente para sustentar o próprio vício" (Apelação Criminal nº 3000574-96.2013.8.26.0363 - Relator Desembargador Paiva Coutinho J. 12.2.2020).

Assim não fosse, a situação de usuário de drogas não excluía de traficante, uma vez que "Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (TJSP AC 9.751-3 Rel. Gonçalves Sobrinho RJTJSP 75/343).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael RJTJSP 101/498).

Não prospera igualmente a alegação do Defensor Público quanto a sua não concordância e desconfiança sobre a lisura da confecção do laudo pericial de fls. 89/90, primeiro, porque não há que se colocar em dúvida toda a ação policial que laborou dentro do estrito cumprimento do seu dever, observando e respeitando todos os requisitos no que concerne a localização, apreensão e transporte de todos os elementos e objetos referentes ao crime em apreço, e segundo, causa estranheza que

somente agora, em sede de alegações finais quer por em dúvida o trabalho da Polícia Técnica, além de que, houve oportunidade para que impugnasse o referido laudo, e não o fez. O próprio réu em seu interrogatório, na presença do Defensor Público disse que é usuário de maconha, cocaína e crack, e todo tipo de droga, o que não causa nenhuma estranheza ou dúvida de que também comercializa todo tipo de droga, embora fora apreendida somente maconha na oportunidade. Crível é, que o laudo está regularmente elaborado dentro dos ditames da lei, portanto não paira qualquer dúvida quanto a alegação da defesa.

Quanto à destinação dos entorpecentes apreendidos nos autos, imperioso salientar que o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos não é perceptível logo de início, mas através das circunstâncias externas do caso concreto, as quais acabam por traduzir a intenção dos agentes.

Na hipótese dos autos, a droga apreendida, aliada ao modo como foram encontradas, denota sua destinação ao comércio ilegal. Importante ressaltar, inclusive, que tanto no veículo do autor como escondido em sua residência, ambas demonstram a principal destinação das drogas, em maior gravidade, uma folha de papel com anotações diversas que contem contas, dados pessoas, valores, altíssimos para quem é motorista de aplicativo, bem como a balança encontrada na residência.

É o quanto basta para embasar a condenação.

Nesse sentido: "CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Circunstâncias que induzem a caracterização do delito. A existência de denúncias anônimas, a diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, parte embalada e pronta para a venda clandestina, são circunstâncias que induzem a caracterização do tráfico." (Apelação Criminal n.º 223.036-3 - Sorocaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 01.07.97 - V.U.);

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Circunstâncias que evidenciam a condição de traficante - Recurso não provido. Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu, no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a sua prisão." (Apelação Criminal n.º 152.279-3 - Marília - 3ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 19.06.95 - V.U.).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de co-réu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos." (Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado.

Nesse sentido: "Não é indispensável a aprova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (TJSP RT 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3,3.8.94, p.8745);

"Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão" (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

Diante de tudo que foi amealhada aos autos, impossível acolher o pedido da Defesa do réu para desclassificação do delito de tráfico para o de porte de droga para consumo pessoal, já que, ao contrário do que alega a defesa, as provas produzidas são suficientes para crer que o réu realizava efetivamente o comércio de drogas na residência e permitia que os usuários usassem a droga comprada no mesmo local, procedendo a ação penal como pedido na denúncia.

Por fim, conclui-se, destarte, que o réu realizara conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes. Por tudo isto é que procede a ação penal e é de rigor a condenação do réu por tráfico de drogas.

Passo a dosagem da pena.

Verifica-se que consta em sua folha de antecedentes criminais de fls. 33/37, que já foi condenado recentemente por grave crime de roubo agravado, Não é reincidente e nem essa condenação por falta de trânsito em julgado pode ser levada em consideração para configurar maus antecedentes.

Entretanto, impede ela a aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, já que demonstra ser o réu ser pessoa dedicada há algum tempo a prática crimes, e de crimes graves como o roubo e o tráfico de drogas.

Portanto, na dosagem da pena, levo em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, que lhes são desfavoráveis, fixo a pena base acima do mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e a pagar a multa de 500 (quinhentos) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Na segunda fase, nenhuma agravante ou atenuante há de ser considerada.

Na terceiro e derradeira fase da dosimetria, ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição da pena, de modo que a torno definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e a pagar a multa de 500 (quinhentos) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia, principalmente, em razão de estar respondendo pelo delito de roubo e de que havia vários objetos em sua residência que demonstram ter o réu personalidade voltada para a prática de crimes.

Não faz o réu jus a redução da pena do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e de acordo com o artigo 44, da Lei nº 11.343/06 impede qualquer benefício ao réu.

A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8072/90, com a redação dada pela Lei n.º 11.464/06, o que não fere qualquer princípio constitucional, uma vez que está em conformidade com o disposto no art. 5.º, incs. XXXIX, XLVI e XLIII, da Constituição Federal.

Ademais, é incompatível outro regime, pois se trata de crime equiparado a hediondo, portanto, de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade, inclusive, por ser possuidor de antecedentes, único compatível com sua condição.

Inviável qualquer substituição diante do montante da pena, pelos mesmos motivos acima expostos.

Incabível o "sursis", por não preencher os requisitos do artigo 77, inc. II, do Código Penal e por ser incompatível com o regime semiaberto previsto na Lei 8072/90.

ISTO POSTO e o que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu PAULO SÉRGIO COSTA SOUZA, RG: 56074354, nascido em 01/01/1996, natural de Delmiro Gouveia - AL, filho de LUIZ CARLOS SOUZA e MARIA APARECIDA COSTA CORREIA, a cumprir a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e a pagar a multa de 500 (quinhentos) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia, como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Ainda sobrevivem os motivos da decretação da prisão preventiva do réu nestes autos e por ter respondido todo o processo preso, agora imponho-lhe a obrigação de recolher-se à prisão para poder apelar desta sentença.

INCONTINENTE, comunique-se a sentença no presídio que ele se encontrar.

Quando da execução a multa deverá ser corrigida monetariamente a partir da data dos fatos da denúncia.

Determino a imediata destruição dos objetos apreendidos nos autos posto que utilizados para o tráfico conforme demonstrou a perícia neles realizada.

Condeno o réu a pagar as custas processuais. Porém, atento aos elementos constantes

do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita. Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA